

1502550-54.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que o acusado reside no mesmo condomínio que o depoente.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não existe, nos autos, qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502550-54.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502550-54.2021.8.26.0616 - 1115/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2317687/2021 -

Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba, 21534950 - Delegacia de Polícia de

Itaquaquecetuba, 5984/21/304 - Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Wallace Domiciano Ximenes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

FELIPE WALLACE DOMICIANO XIMENES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 12h45min, na Rua Rosa, nº 120, Vila P. Neto, Calmon Viana, nesta comarca de Poá, nas proximidades do estabelecimento de ensino Escola Municipal Eneida Costa Assunção Farabello, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 29 porções de cocaína, pesando 20g; 38 porções de maconha, pesando 42,75g; 29 porções de crack, pesando 3,43g, além de 9 frascos contendo "lança-perfume".

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 81, 89/90).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022 (fls. 91).

O réu foi citado (fls. 108).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 5, 8/11), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), laudos de constatação (fls. 28/31, 68/70), pesquisa sobre o local dos fatos (fls. 67) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 68/70, 71/73).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu alegou que “que não é verdade os fatos narrados pelos guardas, que trazia consigo apenas três pedras de crack e uma “paranga” de maconha, que não é traficante, que mora no mesmo condomínio que um dos guardas e já tem uma desavença com o mesmo e sua esposa, que a esposa do guarda brigou com o interrogado no Natal do ano passado e por isso ficou essa desavença, que onde o GCM o vê o aborda, que hoje o GCM viu o indivíduo que estava vendendo drogas e deixou o mesmo correr, abordando apenas o interrogado, que é apenas usuário.” (fls. 11).

Em juízo, foi decretada sua revelia.

A versão do acusado fornecida no distrito policial, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos.

Kelvin Leonardo de Oliveira Marques, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento preventivo quando visualizou o réu descartando em uma sacola plástica que estava no chão. Narrou que, ao perceber a presença da viatura, ele tentou disfarçar e começou a andar. Disse que decidiu abordá-lo. Em seu poder, foram localizados cinco invólucros de droga e certa quantia em dinheiro. Explicou que voltou ao local onde a sacola estava e, dentro dela, foram encontradas porções de cocaína, 'crack' e maconha, além de lança-perfume. Questionado, o réu nada disse. Destacou que as porções encontradas em poder do acusado eram idênticas àquelas localizadas no interior da sacola. Acrescentou que, perto do local da abordagem, a duzentos metros de distância, existe uma escola municipal. Negou conhecer o acusado.

Semelhante é o depoimento de Alexandre Guarnieri, que acrescentou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que o acusado reside no mesmo condomínio que o depoente.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)” (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, apesar de ter alegado, no distrito policial, que conhecia um dos guardas municipais, porque mora no mesmo condomínio e já teve desentendimento com ele, tal

afirmação ficou isolada nos autos, principalmente porque não indicou, em juízo, motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação e o comprovou.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Vale lembrar que eventual consumo de entorpecente não afasta a traficância, já que o usuário é um potencial traficante, que faz da mercancia ilícita a forma de sustento de seu vício.

Nessa toada:

"TÓXICOS - Tráfico - Desclassificação para uso próprio - Descabimento - Agente surpreendido quando guardava cerca de 200 gramas de cocaína - Expressiva quantidade da droga apreendida que, aliada à maneira como estava acondicionada, aos depoimentos dos policiais e ao fato de o réu se dizer desempregado, evidencia a prática do tráfico de entorpecente, sendo que o fato de o acusado ser usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, mesmo porque o comércio ilícito é freqüentemente utilizado para obtenção do dinheiro necessário à manutenção do vício e ao próprio sustento - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 993.08.026446-5 - Araras - 9ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Coelho - 23.07.08 - V.U. - Voto n. 6513).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

"Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes" (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Observa-se ainda que está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a conduta do acusado foi praticada próximo a escola (fls. 67). E quando a lei previu a aludida causa de aumento, assim o fez diante da facilidade de disseminação do tráfico em locais onde há aglomeração de pessoas.

No caso em tela, a traficância foi praticada a quatrocentos metros de distância de estabelecimentos de ensino, cujo percurso a pé leva cinco minutos, conforme documento de fls. 67. Com essa distância, o acusado poderia se deslocar facilmente para tal lugar, em pouco tempo, onde há um maior número de pessoas e lá praticar o tráfico de drogas. Por este motivo, a pena deve ser agravada.

Este é o entendimento doutrinário:

"Imediações. O termo "imediações" não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele de dirigem" (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; São Paulo; 2007; p. 135). Importante esclarecer que a aludida causa de aumento tem natureza objetiva, sendo desnecessária a demonstração de que a mercancia ocorria no estabelecimento de ensino ou objetivava atingir os alunos da instituição. Logo, para sua incidência, basta que a ação criminosa tenha sido praticada nas imediações, como é o caso dos autos.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime

esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98" (RT 772/568). "Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940). Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (mais de noventa porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou, na delegacia de polícia, que trabalhava como entregador, mas não demonstrou tal atividade). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Logo, elevo a sanção em 1/6, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 675 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento descrita na denúncia, razão pela qual acresço à pena a fração de 1/6, totalizando 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu, embora não ostente maus antecedentes, foi preso em poder de considerável quantidade de entorpecentes (quase cem porções), o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas.

Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou trabalho lícito, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste

modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Uma vez que respondeu ao processo solto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar FELIPE WALLACE DOMICIANO XIMENES à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 785 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 6 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA